

0000313-61.2022.8.26.0075

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000313-61.2022.8.26.0075 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000313-61.2022.8.26.0075

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313777/2020 - DEL.POL.BERTIOGA, 15247163 - DEL.POL.BERTIOGA, 3068/20/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2313777 - DEL.POL.BERTIOGA

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

FABIO RIBEIRO MACHADO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Consta na denúncia que: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de dezembro de 2020, às 15h00, na Rua Silma Silva de Faria, 2012, Área Rural, nesta cidade e comarca de Bertioga FABIO RIBEIRO MACHADO, vulgo "FB", qualificado a fls. 13 e CAROLINA DA SILVA MARQUES, qualificada a fls. 13, agindo com unidade de propósitos e desígnios entre si, mantinham em depósito, em sua residência, onde exerciam o poder familiar da filha de 4 anos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 1176 (um mil cento e setenta e seis) porções de cocaína, pesando 1.175kg (um quilo cento e setenta e cinco gramas); 95 (noventa e cinco) porções de skunk, pesando 120g (cento e vinte gramas); 385 (trezentos e oitenta e cinco) porções de maconha, pesando 1.355kg (um quilo trezentos e cinquenta e cinco gramas); 01 (um) tijolo de maconha, pesando

860g (oitocentos e sessenta gramas); 939 (novecentos e trinta e nove) porções de crack, pesando 220g (duzentos e vinte gramas) e, ainda, um pacote com diversas embalagens plásticas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação provisória de fls. 07/08, fotografias de fls. 24/28 e laudo químico toxicológico definitivo de fls. 95/98. Segundo apurado, a Polícia Civil recebeu a informação da prática de tráfico de drogas no endereço dos fatos, razão pela qual diligenciaram no local e foram recebidos pela denunciada, que permitiu a entrada dos agentes públicos no interior do imóvel e, de pronto, confessou a prática do crime. Em busca no interior do imóvel, os agentes públicos notaram forte odor de substâncias entorpecentes e, assim, encontraram as porções das drogas descritas guardadas em duas mochilas escondidas atrás de uma cortina. Presa em flagrante, a denunciada disse que mora no local com Fabio que, entretanto, fugiu ao notar a presença dos policiais civis, a deixando com a filha de 04 (quatro) anos e grávida de 08 (oito) meses. Diante dos fatos, a denunciada foi presa em flagrante e conduzida ao Distrito Policial. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida, as circunstâncias do flagrante e as anotações acostadas a fls. 29/32 são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros. Em audiência de custódia, concedeu-se liberdade provisória a Carolina da Silva Marques (fls. 75/80).

Oferecida a denúncia, decretou-se a prisão preventiva de FABIO RIBEIRO MACHADO (fls. 117/118).

Defesa prévia às fls. 205/207.

Diante da prisão preventiva, desmembrou-se o feito em relação a FABIO RIBEIRO MACHADO (fl. 222).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado (fls. 286).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade delitiva restou demonstrado por: a) auto de prisão em flagrante (fls. 06/07); b) auto de constatação (fls. 12/13); c) boletim de ocorrência (fls. 18/20); d) laudo toxicológico (fls. 100/103).

A testemunha Luciano Boettger Anderson declarou que: tentou procurar o relatório, mas não encontrou nada sobre o menino. Olhando para ele, não se recorda dos fatos.

É um casal, não é? [LIDA A DENÚNCIA] Recorda-se que tinha uma denúncia. Lembra-se que havia um irmão, que se dizia do PCC. Lembra-se que foi recebido por uma moça grávida, que autorizou a entrada. Sentiu odor, tendo localizado uma mochila.

Recorda-se que, quando estava saindo, ter visto o rapaz passando de moto com o capacete aberto. Foi somente a mulher grávida que foi levada para a Delegacia de Polícia. A denúncia é que ele segurava a droga para distribuição nos locais de venda. Não sabia nem o rosto dele. Não se recorda se participou de outras diligências. Era uma farta quantidade de drogas. Não se recorda se foram apreendidos outros objetos. Ela disse que era residência do casal.

Interrogatório 40 anos. Solteiro. Tem dois filhos e uma enteada. Ajudante geral. Tem antecedentes criminais. Dia 16 de dezembro foi encontrado na casa onde morava. Não estava em casa. Estava a Carolina, que estava grávida. Não é mais envolvido no crime. Não tem vulgo FB. Não faz parte de facção ou de partido nenhum. Estava passando situação difícil. Encontrou um conhecido das antigas, conversando com ele que o aluguel estava atrasado. Ele ofereceu duas oportunidades: um horário na boca ou guardar uma mochila com drogas. Ele ofereceu uma cesta básica e R\$ 600,00. A esposa do declarante não tinha ciência de nada. Não falou nada para ela, já que ela não aceitaria. Dia 17 a mulher foi solta, tendo a filha nascido logo em seguida. Essa pessoa ligou na sexta-feira. Não vinha guardando drogas, essa foi a primeira vez. Ela questionou de onde tinha tirado o dinheiro, tendo o declarante a convencido que era um empréstimo. No dia 14 pegou a droga. No dia 16 não estava em

casa, sendo informado por vizinhos que teria havido a prisão. Bateu o desespero. A esposa nunca foi envolvida e é inocente. Não achou que poderia prejudicar ela. Achou estranho a rápida apreensão das drogas, já que ninguém sabia de nada. Não passou com moto em frente à casa. Só não foi xingado de santo pela esposa. A família dela não aceitou a situação. Está muito arrependido e está aqui para pagar pelo próprio erro. Não é traficante e não ficou em biqueira.

Há, portanto, prova robusta para a condenação.

A versão do policial é corroborada pela confissão do acusado quanto à apreensão das drogas em mochila armazenada na residência deste. Em juízo, o réu confessou que receber os entorpecentes para manter em depósito em favor de terceiro não identificando, incidindo no tipo penal do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. Há, ademais, anotações relativas ao tráfico de drogas (fls. 34/37) que denotam que o entorpecente não se destinava ao consumo pessoal, tendo ou não o réu praticado outra conduta além do armazenamento.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do?modus operandi?da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, observo que o réu é reincidente (processo 1500628-32.2018.8.26.0535), bem como maus antecedentes (0001085-84.2007.8.26.0516) afastando o cabimento do benefício. Ademais, pesa em seu desfavor a elevada quantidade dos entorpecentes, conforme laudo toxicológico supracitado, bem como a natureza destes.

Rejeito, contudo, a causa de aumento de pena do artigo 40, II da Lei 11.343/2006, por ausência de elementos suficientes que denotem que a conduta foi destinada a atingir criança ou adolescente. Observo que a conduta do acusado foi destinada ao armazenamento dos entorpecentes em sua residência para posterior entrega a terceiro. Não há elementos concretos que permitam concluir que o bem estar da criança tenha sido afetado pela conduta, não sendo o fato de se tratar de

residência familiar suficiente para atração da causa de aumento, sob pena de responsabilidade objetiva.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, conforme já fundamentado, o réu ostenta condenação além do período depurador. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas pesam em desfavor do réu.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa (elevação de 1/5, considerando duas circunstâncias especiais desfavoráveis e uma circunstância genérica).

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343.2006, conforme fundamentação retro.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o fechado, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR FABIO RIBEIRO MACHADO ao cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não obstante o encerramento da fase instrutória, ainda permanecem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Em especial, pesa em desfavor do réu a quantidade e a variedade de drogas, bem como a sua prisão em contexto de abastecimento de ponto de venda de drogas para terceiro ainda não identificado. Há, portanto, prognóstico negativo em caso de eventual libertação, demandando a manutenção da prisão preventiva para preservação da ordem pública. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra, expedindo-se guia de recolhimento provisória.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II).

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a

vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).
Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP. Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA